

1500293-84.2020.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... consigo e guardava, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado pela acusação, a ré e o adolescente Richard Gabriel se associaram para o fim de juntos, praticarem o crime de tráfico de drogas. Para tanto, recebiam grande quantidade de entorpecentes e se dirigiam para o local acima mencionado para o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500293-84.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500293-84.2020.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

POLYANA KEILA DE ABREU

Vistos.

Polyana Keila de Abreu foi denunciada pelo Ministério Público porque, em data não determinada, anterior ao dia 29 de março de 2020, se associou ao adolescente Richard Gabriel dos Santos Leite para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Além disso, consta da denúncia que a ré Polyana Keila de Abreu, no dia 29 de março de 2020, no período da tarde, na Rua Antônio José Carneiro de Souza, nº 286, Bairro Três Marias, nesta cidade e comarca de Taubaté, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Richard Gabriel dos Santos Leite, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado pela acusação, a ré e o adolescente Richard Gabriel se associaram para o fim de juntos, praticarem o crime de tráfico de drogas. Para tanto, recebiam grande quantidade de entorpecentes e se dirigiam para o local acima mencionado para o fim de comercializá-lo aos usuários.

Na data dos fatos, a ré, previamente mancomunada com o adolescente Richard Gabriel, trazia consigo 16 pedras de crack, subproduto da cocaína, com peso líquido total de 3,29g, escondidas no bolso traseiro de sua bermuda; enquanto o adolescente trazia consigo outras duas pedras da mesma droga, embaladas da mesma forma, com peso líquido total de 0,46g, escondidas em sua boca, além da quantia de R\$ 116,00, e um aparelho de telefone celular pertencente a ré, oportunidade em que foram avistados pelos policiais militares em atitude suspeita, pois demonstraram nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura.

Em revista pessoal, os agentes públicos localizaram a droga que se encontrava na posse da ré e do adolescente. Após buscas realizadas nas proximidades, localizaram outras 17 porções da mesma droga e embaladas da mesma forma daquelas apreendidas em poder da ré e do adolescente, com peso líquido total de 4,44g escondidas na parte inferior do portão de uma obra, o que ocorreu por indicação de um transeunte que avisou os policiais de ter visto o adolescente mexendo naquele local, do que se infere que esta droga também estava na posse da dupla e seria destinada ao comércio ilegal por eles ali exercido.

A droga foi regularmente apreendida e submetida a exame de constatação.

Diante da quantidade significativa de droga apreendida e pelas circunstâncias da prisão, fica evidente que a droga era destinada ao tráfico ilegal.

Busca, assim, a condenação da ré como incurso no artigo 33, caput, e 35, ambos combinados com artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 65/67.

Citada (fls. 87), a réapresentou resposta escrita à acusação às fls. 96.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Felipe Moreira Pinto da Rocha, Grazielle dos Santos Xavier e Keroliny Tatiane de Abreu, procedendo-se ao interrogatório do réu. Posteriormente o Ministério Público e a Defesa apresentaram memoriais.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Ressaltou que as versões apresentadas pela ré são mentiras e não restam dúvidas de que ela estava associada para a prática do crime de tráfico de drogas com o adolescente Richard Gabriel dos Santos Leite. Em que pese a negativa de autoria, mencionou que os agentes públicos foram enfáticos quando disseram que localizaram droga na posse de ambos, além de outras dezessete pedras de crack encontradas na parte inferior do portão de uma obra, as quais estavam embaladas de forma semelhante às outras. Em concordância com isso, a ré confessou informalmente a prática da mercancia ilícita aos policiais militares, justificando que passava por dificuldades financeiras. Nesse sentido, afirmou que a versão apresentada por ela é pouco crível, uma vez que disse não conhecer o adolescente Richard Gabriel e que apenas teria emprestado o aparelho de telefone celular para ele, todavia, o próprio adolescente apresentou versões contraditórias, primeiramente dizendo para os policiais que não a conhecia e depois informando que ela seria sua tia. Salientou que, no caso dos autos, não há qualquer razão para desconsiderar as palavras das agentes de segurança, ou questionar os seus relatos. Outrossim, manifestou que os relatos dos policiais foram confirmados pelos dados extraídos do aparelho de telefone celular de propriedade da ré, apreendido em poder do adolescente. Apontou que neles é possível verificar com clareza que a ré estava associada ao adolescente e a outras pessoas para a venda de drogas, o que fazia de forma habitual no local onde acabou presa em flagrante delito. Além disso, é certo que a ré se dirigia diariamente ao local dos fatos a fim de comercializar

entorpecentes, os quais recebia de outra pessoa incumbida de realizar a distribuição da droga. Ademais, a venda era feita por cotas, sendo que sua remuneração era feita com parte do dinheiro obtido pela venda dessas cotas. O adolescente Richard, assim como a ré, tinha a função de vender a droga aos usuários no local onde também acabou detido. Garantiu que todos esses elementos podem ser analisados no relatório de extração encaminhado anexo ao laudo pericial nº 144.652/2020, o qual confirma que, apesar do registro em nome de Léo ou Léo Abreu, assim como em todas as redes sociais, a responsável pelas contas era a ré Polyana. Nesse cenário, alegou não haver dúvida da dedicação habitual da ré com o tráfico de drogas e sua vinculação à criminalidade organizada, a qual, de fato, estava associada com o adolescente Richard e a outras pessoas não identificadas, de forma perene e organizada, com distribuição de tarefas, para o tráfico de drogas. Sendo assim, requereu a condenação da ré nos exatos termos da denúncia. Na fixação de pena, em sua primeira fase, vislumbrou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo em vista a quantidade e lesividade da droga apreendida, que é significativa, o que demonstra sua distribuição atingiria um número elevadíssimo de viciados, causando destruição de muitas famílias. Na segunda fase de dosimetria da pena, não visualizou a incidência de agravantes, sendo que eventuais atenuantes não podem reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de dosimetria da pena, afirmou incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da dedicação habitual da ré ao tráfico de drogas e da prática também do delito de associação, demonstrando que a ré está envolvida de forma habitual na atividade criminoso e que não faz jus ao referido benefício. De outro lado, postulou a aplicação da causa de aumento de pena referente à prática do crime em associação com adolescente, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, em relação a ambos os delitos. Destacou o concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas. Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, pediu o estabelecimento do fechado, ante a quantidade de pena e a hediondez do delito, sendo este o único compatível com a conduta praticada pela ré. Por fim, por tratar-se de produto de crime, não havendo nos autos provas de sua origem lícita, solicitou que seja determinado o perdimento do dinheiro apreendido.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição da ré como medida de rigor. Ressaltou que, às fls. 65/67, foi deferida a decretação da quebra do sigilo de dados do celular da ré, após requerimento do Ministério Público. Assim, foi elaborado extenso e detalhado relatório dos dados contidos no celular da ré, conforme laudo pericial acostado às fls. 82/85. Nesse sentido, mencionou que, conforme o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada, bem como, no inciso XII, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente, sob pena de nulidade. Ademais, citou o artigo 3º da Lei nº 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, o qual assegura ao usuário desse serviço "à inviolabilidade ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucionais e legalmente previstas", e o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.965/14 (conhecida como Marco Civil da Internet), que regulamenta o uso da internet no Brasil, assegura aos seus usuários o direito "à inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial". Nesse contexto, destacou a preocupação do legislador em proteger a intimidade e a vida privada do indivíduo, mediante a qual instituiu que a análise dos dados telefônicos constante dos aparelhos dos investigados somente é possível após sua prévia autorização ou de prévia autorização judicial, devendo essa ser devidamente motivada, o que não ocorreu no caso concreto. No mesmo sentido, manifestou-se sobre a Lei nº 13.964/19, a qual passou a prever expressamente a nulidade de decisão carente de fundamentação (art. 564, inciso V, do Código de Processo Penal), a fim de evitar arbitrariedades e abusos de poder por parte do

Estado-juiz, como também garante ao jurisdicionado o direito de compreender os fundamentos do julgamento de seu caso. Diante da nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como de inobservância do contraditório, sendo nulas e ilícitas as provas obtidas por meio da quebra de sigilo do celular da acusada, postulou o desentranhamento do laudo pericial acostado às fls. 82/85 e 135, conforme determina o artigo 157, do Código de Processo Penal. Com relação ao delito de associação ao tráfico, afirmou que este não se demonstrou devidamente comprovado, uma vez que incumbe ao Ministério Público demonstrar de forma cabal o liame subjetivo entre os acusados, o que, de fato, não ocorreu no caso em exame. Salientou que era necessária a demonstração da chamada "societas sceleris", isto é, um animus associativo, assim como a presença de estabilidade e permanência da associação, não bastando para tal uma mera reunião ocasional de duas ou mais pessoas. No caso apurado, lembrou que, tanto o adolescente quanto a ré, quando ouvidos na Delegacia, disseram não conhecer um ao outro, além de que ela negou a acusação, em juízo, justificando ser apenas usuária e que estaria comprando drogas, quando o adolescente lhe pediu o celular emprestado. Inclusive, foi a primeira vez comprando drogas naquele local, pois lhe disseram que era a melhor. Diante dos fatos apresentados, foi imputado à ré o crime de associação ao tráfico com o adolescente Richard Gabriel dos Santos Leite pelo simples fato de ambos estarem no mesmo local na posse de drogas. Garantiu que em nenhum momento foi verificado ajuste prévio entre eles no sentido de formação de um vínculo associativo de fato. Ressaltou que a única prova que sugere alguma ligação entre a ré e o adolescente, é o relatório realizado em seu aparelho celular, que é nulo na sua origem, devendo ser desentranhado dos autos. Ainda que não seja reconhecida a nulidade, alegou que na perícia realizada não foi constatada qualquer envolvimento da ré com Richard, uma vez que o número do celular do adolescente sequer estava salvo no celular. Desse modo, ainda que a ré estivesse realizando tráfico de drogas no local, ela estava atuando de forma independente e autônoma, cada um organizando, executando e auferindo as vantagens de sua própria conduta. Em contrapartida, ainda que a conversa seja considerada como válida, reiterou que não há demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre eles, mas apenas um evento esporádico. Na hipótese de condenação, postulou que a pena-base seja fixada no mínimo legal, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, principalmente considerando a primariedade e os bons antecedentes, além de que os fatos imputados a ela não se revestiram de gravidade anormal ou extraordinária que extrapole a já inerente ao crime. Na segunda fase, apontou a presença da atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que a ré contava com 19 anos na época dos fatos. Na terceira fase, vislumbrou o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Postulou que o regime inicial seja o aberto, ante o quantum da pena a ser aplicado e a primariedade da ré, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal. Por fim, tendo em vista a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, a primariedade da ré e o quantum da pena aplicada, manifestou que a ré faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Subsidiariamente, na hipótese de não concessão do redutor, pleiteou a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que inexistem circunstâncias que requeiram o regime mais gravoso, essencialmente em razão da pequena quantidade de droga apreendida, bem como da primariedade da ré.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação da ré como incurso no artigo 33, caput, e 35, ambos combinados com artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Quanto à alegação preliminar de nulidade da decisão que decretou o acesso aos dados existentes no aparelho celular apreendido nos autos, com a devida vênia, não se vê qualquer equívoco ou irregularidade.

A despeito de concisa a decisão, teve ela por base o pedido do Ministério Público que trazia as razões pelas quais entendia possível o acesso, que foram encampadas pelo juízo. Ademais, na época dos fatos a questão era controvertida, até porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal, com base no HC 91867-PA, era da desnecessidade sequer de autorização judicial para acesso ao telefone, que poderia se dar pela própria polícia.

A jurisprudência somente foi superada em data de 20.10.2020, com a decisão proferida nos autos do HC 168052, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Assim, à época dos fatos, de acordo com a jurisprudência dominante, não se mostrava efetivamente necessária a expressa motivação judicial, sendo adequada a autorização judicial procedida na esteira da manifestação ministerial.

Quanto ao contraditório, foi este diferido, sendo que a ré teve plena ciência do relatório produzido, sobre o qual pode se manifestar em alegações finais, exercendo sua defesa de forma ampla.

Rejeito, assim, a alegação de nulidade do acesso aos dados do celular apreendido.

Não havendo outras questões preliminares a se enfrentar, verifica-se que as condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 2/5), auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), laudo pericial provisório (fls. 9/14), termos de depoimentos (fls. 15/16), termo de declaração (fls. 17), termo de interrogatório (fls. 23), laudo pericial definitivo (fls. 62/64), relatório de investigação (fls. 75/76), laudo pericial (fls. 82/85), relatório do aparelho celular (mídia) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste à acusad, em razão da robusta prova atribuindo a ela a prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

A testemunha Felipe Moreira Pinto da Rocha, ouvida em juízo, relatou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina pelo local, quando avistaram a ré e o adolescente, os quais demonstraram certo nervosismo. A partir disso, procederam à abordagem com a ajuda de uma policial feminina. Nesse momento, perceberam que o adolescente demonstrava dificuldades na fala, razão pela qual solicitaram que abrisse a boca, encontrando 2 papelotes de crack, além de dinheiro e um telefone celular na posse dele. Questionado, informou que o celular pertencia à ré, sendo que, em um primeiro momento, disse que não a conhecia e posteriormente afirmou que ela era sua tia. Após buscas pelo local receberam a informação de um transeunte de que o adolescente, momentos antes, estaria mexendo em um portão, onde localizaram outros 17 papelotes de crack. Nesse cenário, o adolescente foi novamente perguntado, todavia, disse que estava no local apenas para comprar drogas, negando a prática da mercancia ilícita. Em contrapartida, a ré confessou que estava vendendo entorpecentes no local, alegando que passava por dificuldades financeiras. Mencionou que localizaram 16 papelotes de crack em sua posse, com características semelhantes aos outros. Esclareceu que a ré e o adolescente estavam cada um de um lado da rua. Afirmou que não os conhecia anteriormente.

A testemunha Grazielle dos Santos Xavier, ouvida em juízo, narrou que estavam em patrulhamento de rotina pelo local quando procederam à abordagem da ré e do adolescente, que estavam em lados opostos da rua, além de demonstrarem nervosismo.

Com a ré, foram encontrados 16 papelotes de crack e dinheiro. Questionada, justificou que passava por dificuldades financeiras e estava traficando para levar leite à filha. Com o adolescente foram apreendidos 2 papelotes de crack, que estavam dentro de sua boca, e a quantia de R\$ 116,00. Afirmou, ainda, que a ré era sua tia, ratificando depois que não a conhecia. Confirmou que o celular da ré foi apreendido na posse do adolescente. Afirmou que nenhum deles mencionou o tráfico em associação. Em busca pelas proximidades, encontraram 17 papelotes de crack, mediante informação de um transeunte, em um portão próximo à ré Polyana. Na ocasião, o adolescente confessou ser usuário de drogas e a ré negou. Não os conhecia anteriormente.

A ré Polyana Keila de Abreu, interrogada em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Justificou que, na data dos fatos, foi até o local para adquirir drogas, pois é usuária, ocasião em que emprestou seu celular ao adolescente Richard Gabriel, que pretendia ir embora. Em seguida, foi abordada pelos policiais. Afirmou que os entorpecentes adquiridos foram vendidos por Richard, sendo que não o conhecia anteriormente. Alegou que pagou R\$ 116,00 pela droga e o dinheiro era fruto de seu trabalho em um lava-rápido, onde recebe R\$ 200,00 semanais. Durante a abordagem, tinha cerca de R\$ 20,00 em sua posse. Na oportunidade, recebeu a informação de que aqueles entorpecentes eram de melhor qualidade, por isso, apesar de não morar próxima ao endereço, deslocou-se até lá de ônibus para comprar. Mencionou ser usuária de crack e maconha há muitos anos. Afirmou que localizaram drogas e dinheiro com Richard Gabriel, mas não soube dar detalhes. Não presenciou a apreensão da droga perto do portão. Disse ser solteira, não ter filhos e morar com a namorada; não tem outros processos.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

São dois os delitos nos quais foi a ré denunciada, sendo artigo 33, caput, e 35, da Lei de Drogas, que dispõem:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. "

Verifica-se pela prova produzida atenta ao contraditório e à ampla defesa que a conduta da ré encontrou plena subsunção em ambos os artigos.

Quanto ao tráfico, registro que o relato dos policiais foi firme e assertivo no sentido de que encontraram a droga no bolso da ré e próximo dela, em um portão, mais papelotes de cocaína, além daquela que o adolescente escondeu em sua boca.

Ao relato dos policiais soma-se o encontro da droga, que vem corroborar os fatos narrados trazidos tanto na delegacia quanto em juízo.

Além disso, ambos policiais relataram que no momento da prisão a ré confessou os fatos, o que por diversas vezes acontece nas hipóteses de flagrante, sendo que, na delegacia, alteram sua versão.

Da mesma forma encontra-se provado o delito descrito no artigo 35, da Lei de Drogas. As conversas extraídas do telefone celular de propriedade da ré dão conta de que entre ela, o adolescente e outros indivíduos, havia uma associação, cada

qual com sua tarefa previamente definida, para venda e distribuição de entorpecentes.

Como bem apontou o Ministério Público, a ré se dirigia ao local dos fatos diariamente com o fim de comercializar as drogas recebidas de outra pessoa. A venda se dava por meio de cotas, pelas quais a ré recebia sua remuneração, como deixam bem entrever as conversas travadas e extraídas do celular.

De se anotar a conversa travada pela ré com, ao que tudo indica, um mototaxista, em que reclama do preço cobrado, dizendo que vai todo dia para o mesmo local por um preço menor, referindo-se ao lugar de sua prisão (onde realiza o tráfico).

Ademais, as conversas extraídas dão conta de inúmeros fatos que comprovam, sobremaneira, a associação para o tráfico, deixando claro o *modus operandi* da associação, que se mostra perene.

Acerca da questão, forçoso reconhecer que, como se vislumbrou, não se tratou de um concurso ocasional de agentes, mas sim de duas pessoas aliadas a outras não identificadas, com os mesmos fins, concatenados para a difusão de drogas, de forma constante e permanente, configurando, inequivocamente, a associação para o tráfico.

O envolvimento do menor é também comprovado tanto pela prisão da ré, momento em que ele estava a seu lado, na posse do celular dela, assim como pelas conversas, especialmente aquela que teve no dia de sua prisão, quando se comunicava com sua namorada, dizendo que o Gabriel estava ali com ela.

Assim, não há dúvida quanto à responsabilidade da ré pelos crimes a ela imputados.

Quanto às teses defensivas, verifica-se que a alegação em autodefesa afirmando que era viciada e ali estava para adquirir drogas para seu consumo próprio vai de encontro às provas produzidas.

A quantidade de droga com ela encontrada dá conta de que os entorpecentes serviam à traficância. Além disso, informalmente aos policiais a ré afirmou que ali estava a serviço do tráfico.

Some-se a isso as provas colhidas no relatório extraído de seu celular, dando conta da traficância.

Quanto à defesa técnica, não há propriamente insurgência contra o reconhecimento do tráfico, e, excetuando a preliminar lançada – já devidamente afastada – busca o não reconhecimento do delito de associação.

Contudo, as razões acima explicitadas dão conta da existência da associação, de forma pormenorizada, com apoio, em especial, nas conversas extraídas do celular da ré, que se encontrava na posse do adolescente no momento de sua prisão, evidenciando o laço que os une na empreitada criminosa.

Importa afirmar, por outro lado, não ser o caso de se reconhecer a figura privilegiada disposta no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/06. Isso porque foi provado que ela pertence à associação para o tráfico, o que afasta, de plano, o privilégio referido.

O fato de ser primária e sem antecedentes deve se conjugar com a não dedicação a atividades criminosas e à não integração de organização criminosa, o que não é o caso da ré.

A ré era, na data dos fatos imputável. Tinha pleno conhecimento da ilicitude da conduta praticada e preferiu agir contrariamente à lei.

A prova é certa, segura e dá conta da prática do crime pela ré, que deve responder pelo delito praticado.

Estabelecida a responsabilidade da ré, passa-se à dosimetria da pena, com fundamento no artigo 68, do Código Penal, atento ao critério trifásico desenvolvido por Nelson Hungria e obediente à individualização da pena.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A natureza da droga e sua quantidade principalmente não pesam em desfavor da ré, pois se cuida de pequena quantidade que não justifica o aumento da pena base.

No que se refere à personalidade do agente - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que a ré mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte da ré, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa - que não é absoluta - demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o réu se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do

agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a

pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço <http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

"...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

"Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base..."

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

"(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras."

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

"Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o

julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisum que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escoreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

No que respeita à culpabilidade o que se vê é natural à espécie.

Não ostenta a ré maus antecedentes.

Acerca da conduta social da ré não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico saúde pública, não havendo falar-se em comportamento da vítima.

Assim, na fixação da pena-base, na consideração da personalidade negativa, eleva-se a pena de ambos os delitos em 1/6, fixando-se para o delito de tráfico a pena de 5 anos 10 meses de reclusão e 583 dias-multa; para a associação 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, que faz atenuar a pena em 1/6, tornando ao mínimo legal de 5 anos e 500 dias-multa para o tráfico, e 3 anos e 700 dias-multa para a associação para o tráfico, em conformidade com a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, não havendo agravantes.

Na terceira etapa, não há causa de diminuição de pena. Há, contudo, causa de aumento consubstanciada no envolvimento de adolescente, que faz elevar a pena em

1/6, fixando-se, definitivamente, para o delito de tráfico a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa; para a associação 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Diante do concurso material, impõe-se a soma das penas. Dessa forma, a pena definitiva é fixada em 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.399 dias-multa.

O regime inicial de pena será o fechado. Justifica-se o regime mais rigoroso não só pela quantidade de pena impingida à ré, mas porque se trata de tráfico e de associação, delitos ambos de enorme gravidade e que demandam uma resposta consentânea do Estado.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira da ré, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Pela quantidade de pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que exige apenação menor de 4 anos, em conformidade com o artigo 44, do Código Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena porque exige o artigo 77, do Código Penal, pena máxima de 2 anos.

Anoto, ainda, que a despeito da Resolução n 5, do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a conversão e o sursis não se fazem adequados à prevenção e repressão do crime em espécie, pois, como já se decidiu, "os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com reação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, 'os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente' (TJSP, apelação 0026205.40.2008.8.26.0405).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade. Registro que no decorrer do processo esteve ela em liberdade, não se vislumbrando necessidade de alteração desse estado, prestigiando assim a presunção da inocência, pois ausentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar.

Como afirma Ricardo Schmitt, "como regra geral, temos que se o sentenciado se encontra solto, em liberdade plena no momento da sentença, tendo permanecido nesta situação durante a instrução processual, em princípio possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se existir algum motivo ponderoso à aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou, em último caso, de decretação de sua custódia preventiva" (Sentença Penal Condenatória, 8.ª ed., Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p. 443)

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixa-se de cumprir o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito da ré por conta do período que este permaneceu preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes - 6ª Turma do Superior

Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal.

Com relação ao dinheiro, não foi comprovado que advinha de lícito labor, impondo-se o perdimento.

Registro que seriam fatos de prova relativamente facilitada. Prova documental, no caso concreto, seria a única hábil à comprovação das alegações, mas não veio para os autos.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para condenar a ré Polyana Keila de Abreu à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, além de 1.399 dias-multa, como incursa nos artigos 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com início de cumprimento de pena em regime fechado, concedendo à ré o direito de recorrer em liberdade, condenando-a, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação da ré;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 9 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA